

0000855-04.2018.8.26.0210

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDERSON VALENTE

Comarca: Guaíra

Foro: Foro de Guaíra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaíra

Foro de Guaíra

1ª Vara

Av. 17, 414, Guaíra - SP - cep 14790-000

0000855-04.2018.8.26.0210 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000855-04.2018.8.26.0210

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Barbara Adrielle da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON VALENTE

Vistos.

I. BÁRBARA ADRIELLE DA SILVA, qualificada nos autos a fls. 17, foi denunciada e viu-se processada como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 16 de abril de 2018, por volta de 20h50min, na Avenida 33 nº 1.210, Casa B, nesta cidade e Comarca de Guaíra, teria trazido consigo e teria em depósito, para fins de

tráfico, treze porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 9,0 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que “Na data dos fatos, policiais militares receberam delação anônima informando que a denunciada estava traficando drogas no cruzamento da Avenida 25 com a Rua 40 e, para tanto, escondia as drogas sob um monte de telhas existente nas proximidades do referido logradouro. Em diligências no local indicado, os milicianos depararam com a denunciada mexendo em algo sob um monte de telha.

Os policiais, então, abordaram a denunciada e a submeteram a busca pessoal, oportunidade em que apreenderam em seu poder um aparelho celular e a quantia de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em dinheiro, cf. auto de exibição e apreensão de fl. 11/12.

Ainda, os milicianos dirigiram-se até o monte de telha em que a denunciada mexia e localizaram 2(dois) Eppendorfs contendo cocaína. Em seguida, dirigiram-se até a residência em que a denunciada estava morando e, após efetuarem buscas em seu quarto, localizaram, no bolso de uma calça que estava sobre a cama, mais 11 (onze) Eppendorfs contendo cocaína”.

A denúncia de fls. 106/108 foi recebida em 1º de novembro de 2018 (fls. 138). A Ré foi citada (fls. 222) e apresentou defesa preliminar em fls. 228/233, rejeitada a fls. 235/237. Na instrução da causa foi colhida prova oral e decretada a revelia da Acusada (fls. 284/293).

Em memoriais, o ilustre representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia (fls. 284/285).

A douta Defesa, por seu turno, a fls. 300/311, arguiu preliminar e no mérito afirmou que não existiria prova apta a impor o édito condenatório, pretendendo sua absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para o tipo penal do artigo 28 e, em caso de condenação, a imposição de pena mínima, com substituição da pena corporal por restritiva de direitos e demais consequências daí advindas.

É o relatório.

II. Fundamento e DECIDO.

A preliminar arguida em alegações finais deve ser afastada, porque não houve leitura da denúncia aos policiais militares, mas somente pergunta do representante ministerial sobre o fato, devendo se observar que o advogado signatário dos memoriais, nomeado pela inércia do anterior (fls. 294), não participou da audiência. Não bastasse, sem que os policiais fossem situados sobre o fato ao qual prestariam depoimentos – o que, ressalte-se, não é pela leitura da denúncia – não conseguiriam apresentar qualquer declaração.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está evidenciada com o auto de prisão em flagrante de fls. 02/06, no boletim de ocorrência de fls. 08/10, no auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, auto de constatação preliminar (fls. 13), guia de depósito judicial de fls. 40, auto de exame químico-toxicológico em fls. 166/167, bem como pela prova oral colhida durante a persecução penal.

A autoria é certa contra a Ré que, na fase inquisitorial optou pelo silêncio (fls. 06), ao passo que em Juízo não foi ouvida devido sua revelia (cf. fls. 284/285).

De início deve ser destacado que, como se sabe, o direito ao silêncio é cláusula constitucionalmente assegurada, mas não é crível se acreditar que aquele que tenha sido injustamente preso pela prática de um crime assemelhado ao hediondo tivesse a

frieza de manter-se calado para somente em Juízo informar a prisão equivocada, demonstrando que a Ré nada tinha a indicar em sua defesa no momento de sua prisão, cabendo salientar brilhante excerto de acórdão do E. Tribunal de Justiça Bandeirante, pois ele “assumiu comprometedor, ainda que legalmente tolerada, postura silente, quando é certo que aquele que se vê injustamente acusado, trata, logo, de anunciar a injustiça da acusação, se convidado a falar sobre ela” (TJSP, Ap. 990.09.059887-5, 3ª C.D.Crim., Rel. Des. Geraldo Wohlers, j. 04.08.2009).

Pois bem.

O policial militar Daniel, em fls. 286/288, relatou que possuíam denúncia dando conta que a Ré estaria traficando no local, para lá se dirigindo, a encontrando remexendo em telhas e ali localizaram duas porções de cocaína, de modo que foram até a residência da Acusada, um local que havia lhe sido cedido e com a chave que ela carregada entraram no quarto e encontraram em um bolso de vestes da Ré o restante da droga, bem como aprenderam com ela dinheiro em notas trocadas. Ademais, ela não aparentava estar sob efeito de drogas e não a conhecia, salientando, contudo, que o lugar onde ela inicialmente abordada é amplamente utilizado pelo tráfico e possui constante rotatividade, diante das corriqueiras prisões. No mesmo sentido esse foi o depoimento de seu colega de farda, Aguinaldo, em fls. 289/291.

A testemunha Vinícius disse que tinha cedido um cômodo de sua casa para Ré (cf. fls. 292/293).

A análise das provas indica que a Acusada infringiu o disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343, de 23.06.2006. Isso se deve porque ela trazia consigo e tinha em depósito porções de cocaína, inclusive em conhecido ponto de venda de drogas, o que, aliado à forma em que estavam, o fato de não aparentar que estava sob efeito de entorpecente e a localização de dinheiro em notas trocadas em sem origem lícita, indicam, sem dúvida, a narcotraficância, a confirmar que ela tinha aquele entorpecente para fins de comercialização criminosa, consoante se extrai do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343/06.

Lado outro, o simples fato de ser usuária – sequer comprovado ou mesmo por ela declarado, já que silente na fase inquisitorial e revel na judicial -, não excluiria a possibilidade da narcotraficância, sendo, no mais, condutas que comumente caminham juntas, afastando a pretensão da douta Defesa que visava a desclassificação do delito ao qual denunciada a Ré.

Dessa forma, considerando o quadro posto, descabe se falar em insuficiência probatória. Oportuno salientar que “Nunca é demais lembrar, de outro lado, que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado” (TJSP, Ap. 990.09172372-0, 5ª C.D.Crim., Rel. Des. Pinheiro Franco, j. 03.12.2009).

Nem se olvide pelo fato de a Acusação se embasar somente no depoimento prestado por policiais, que é válido e está em consonância com as demais provas, sem existência de qualquer indicativo de sua imprestabilidade, motivo por que não podem ser descartados, notadamente porque não se ofertou qualquer resistência ao depoimento deles.

A condição funcional, sendo assim, não os torna suspeitos, valendo o princípio de presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados. Nesse diapasão, “Com relação aos depoimentos de policiais, os entendimentos jurisprudenciais têm convergido na direção de que são eles válidos e aptos ao suporte de uma condenação, pois aqueles agentes da autoridade prestam os seus esclarecimentos sob o compromisso da verdade como qualquer testemunha e as suas narrativas devem ser entendidas como verdadeiras até a produção de provas em contrário, com demonstração

da falácia, recaindo o ônus da produção destas na esfera da defesa, situação que inocorreu nos autos.

Pequenas divergências encontradas no cotejo dos depoimentos prestados pelos policiais, sem atingirem o âmago da questão, devem ser desprezadas, posto que podem ser produto do posicionamento dos mesmos quando da diligência efetuada e das tarefas de cada um deles naquele momento, além do entrelaçamento de situações diante do elevado número de ocorrências que tais policiais atendem no dia a dia, sem o comprometimento daquilo que narraram" (TJSP, Ap. 990.08.168537-0, 10ª C.D.Crim., Rel. Des. Otávio Henrique, j. 16.04.2009).

Destarte, passo a dosimetria da pena em relação ao tipo do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade da Ré ou extingam sua punibilidade.

A Ré não ostenta antecedentes criminais certificados nos autos que possam ser considerados para exasperação da pena e, apreciando os parâmetros legais ditados pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que deve a pena-base ser fixada no mínimo legal, por ter agido com dolo normal da conduta, de forma que a estipulo sua pena em 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no menor valor, à míngua da comprovação de suas condições econômicas.

Muito embora a Ré fosse menor de vinte e um anos à consumação do crime, a pena, mantida em seu piso, não pode ser diminuída aquém de seu patamar mínimo, por se tratar de circunstância atenuante (artigo 65, inciso I, do Código Penal). Esta orientação levou o C. Superior Tribunal de Justiça, inclusive, a editar a Súmula nº 231: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Não havendo qualquer demonstração nos autos de que se dedique à atividade criminosa organizada, faz jus à causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. No caso dos autos, dadas as circunstâncias particulares, não havendo qualquer demonstração clara de tratar-se de pessoa envolvida com a criminalidade organizada, reduzo a pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços), totalizando 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no seu menor valor, que torno definitiva ante a inexistência de demais causas legais modificadoras.

Neste ponto, é de se reconhecer que o Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu que o tráfico privilegiado não tem natureza de crime equiparado ao hediondo, verbis: "HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos.
2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa.
3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90.
4. Ordem concedida" (HC 118.533/MS, Relª Minª Carmen Lúcia, j. 23.06.2016).

Desta forma, tomando por base a ausência de hediondez do tráfico privilegiado, assim como sua primariedade e menoridade relativa, sua pena deverá ser cumprida desde o início em regime aberto, o que é aqui consignado por determinação legal (artigo 59, inciso III, do Código Penal) e em face de eventual e futura revogação das penas restritivas de direitos sobre as quais se falará a seguir. Presentes os requisitos previstos no artigo 44 e no seu parágrafo 2º, segunda parte, do Código

Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo em favor de entidade assistencial (artigo 43, inciso I, do Código Penal) e prestação de serviço à comunidade ou entidade pública (artigo 43, inciso IV, do Código Penal), pelo prazo da condenação, que devem ter seu cumprimento fixado pelo Juízo das Execuções Criminais.

Lado outro, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, porquanto o crime apurado é classificado como vago, assim entendido aquele que tem por sujeito passivo a sociedade, destacando, outrossim, que não se comprovou qualquer dano causado em sujeitos passivos secundários (pessoa submetida aos riscos da lesão).

À derradeira, tendo em vista que a Acusada foi condenada como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo com ela localizada quantia em dinheiro e telefone celular vinculada ao crime, evidenciando-se serem resultado da venda de drogas ilícitas, com fulcro no artigo 63, caput, do aludido diploma legal, decreto a perda dos valores e do celular apreendidos com a Ré, que deverão ser encaminhados em favor da União, com o trânsito em julgado desta sentença (artigo 63, parágrafo 1º).

III. Isto posto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e, em consequência, CONDENO a Ré BÁRBARA ADRIELLE DA SILVA, qualificada nos autos, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, com correção monetária a partir do fato delituoso, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em regime aberto, sendo que a pena de reclusão é substituída, por igual prazo, por pagamento de 1 (um) salário mínimo à entidade assistencial e à prestação de serviço à comunidade ou à entidade pública, a ser fixada pelo Juiz das Execuções Criminais. No mais, decreto a perda do dinheiro e do celular apreendidos com ela, em favor da União.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), bem como encaminhe-se o numerário e o celular apreendidos, em benefício da União.

Tendo em vista o regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não se mostra necessária a decretação de sua prisão cautelar, podendo aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, nos termos do artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

São devidas as custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Guaíra, 07 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA